

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 2556

✧ บทความทั่วไป

- ความสับสนของการใช้คำในกฎหมาย : “ไม่ผูกพัน” “หลุดพ้น”
- บทบัญญัติเรื่องศีลธรรมในกฎหมายเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาเครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรม
- มาตรการก่อนการพิพาทคดีปกครองในศาลปกครองฝรั่งเศส
- ที่มา ความหมาย และความสำคัญขององค์ความรู้ดั้งเดิม ทรัพยากรของชนเผ่าพื้นเมือง และทรัพยากรพันธุกรรม และการหลั่งไหลของทรัพยากรเหล่านี้สู่ประเทศ
- การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านจัดสรร กรณีความชำรุดบกพร่องที่เกิดหลังการส่งมอบ
- การคุ้มครองปัญญาท้องถิ่นภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ
- กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน
- การบังคับใช้กฎหมายควบคุมจดหมายสแปม

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

เสือขับรถบรรทุกของไปส่งตอนกลางคืน ระหว่างทางรถยางแตก เสือควรจะเปิดไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนไว้ เพราะถนนมีรถมาก รถอื่นขับมาอาจไม่เห็นและชนท้ายเอาได้ แต่เสารู้ดีว่า สมิงกำลังขับรถตามตนมา เสือต้องการกำจัดสมิงนานแล้ว เพราะชอบมาจีบน้องภรรยาของตน เสือจึงปล่อยรถทิ้งไว้อย่างนั้นเฉย ๆ สมิงขับรถตามมาไม่เห็นรถที่เสือจอดทิ้งอยู่จึงชนเข้าอย่างแรงเสียชีวิต ตำรวจตั้งข้อหาว่าเสือฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่เสือต่อสู้ว่าตนมิได้มีการกระทำใด ๆ เลย รถยางแตกเอง และสมิงก็ขับรถมาชนท้ายเอง แม้ตนมีเจตนาจะให้สมิงตาย แต่ตนก็ได้ลงมือกระทำการใด ตนจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของเสือหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 59 วรรคท้าย บัญญัติว่า “การกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย”

วินิจฉัย

การกระทำตามความหมายของกฎหมายอาญาให้หมายรวมถึงการกระทำโดยการงดเว้นด้วย คือผู้ใดมีหน้าที่โดยเฉพาะให้ต้องกระทำการใดการหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายเช่นนั้นขึ้น แต่ผู้นั้นงดเว้นไม่กระทำการตามหน้าที่นั้น ถือเป็นการกระทำโดยการงดเว้น จากเจตย์เสือขับรถบรรทุกไปส่งของตอนกลางคืน ระหว่างทางรถยางแตก เสือมีหน้าที่ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติจราจรทางบก) ต้องเปิดไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น เพราะถนนมืดมาก อาจมีรถอื่นขับมาแล้วมองไม่เห็น และชนท้ายรถบรรทุกนั้นได้ แต่เสืองดเว้นไม่กระทำการดังกล่าวตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดนั้น โดยมีเจตนาจะให้สมิงตาย เพราะเสารู้ว่าสมิงคือคนที่ขับรถตามตนมา เมื่อสมิงขับรถมาถึงที่เกิดเหตุและชนท้ายรถบรรทุกของเสือนั้นสมิงเสียชีวิต เสือจะปฏิเสธไม่ต้องรับผิดชอบทางอาญาโดยอ้างว่าแม้ตนจะมีเจตนาให้สมิงตาย แต่ตนมิได้มีการกระทำใด ๆ ไม่ได้ เพราะตามกฎหมายอาญาถือว่าเสือกมีการกระทำแล้ว เป็นการกระทำโดยงดเว้น ตามมาตรา 59 วรรคท้าย

สรุป

ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของเสือ เสือต้องรับผิดชอบฆ่าคนตายโดยเจตนา จะปฏิเสธว่าไม่มีการกระทำไม่ได้ เป็นการกระทำโดยการงดเว้น และเป็นการงดเว้นโดยเจตนาด้วย

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ต้องการวัดความเข้าใจของนักศึกษาเรื่อง “งดเว้น” ตาม ปอ. มาตรา 59 วรรคท้าย ซึ่งหมายความว่า ผู้กระทำโดยงดเว้นมีหน้าที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลมิให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ หน้าที่จะต้องกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นได้ 4 กรณี คือ

1. หน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
2. หน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆ ของตน
3. หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ
4. หน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง

หากผู้กระทำโดยงดเว้นมีเจตนาไม่กระทำหน้าที่เพื่อป้องกันผล ผู้นั้นจะปฏิเสธว่าตนไม่มีการกระทำไม่ได้

ปัญหาจากการตอบคำถามของนักศึกษาในข้อนี้พอจะสรุปได้ ดังนี้

1. นักศึกษามักจะจำสับสนกับประเด็นการกระทำโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายอีกกรณีหนึ่ง นั่นคือ “ละเว้น” ซึ่งแม้จะไม่มีบัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 59 ก็ตาม แต่นักศึกษาควรทราบว่า การไม่เคลื่อนไหวร่างกายให้รวมถึงการ “ละเว้น” อันหมายถึงการไม่กระทำในสิ่งที่ เป็น “หน้าที่โดยทั่วไป” ที่ต้องกระทำด้วย ทั้งนี้ คำว่า “ละเว้น” กับ “งดเว้น” มีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า “เสือจะอ้างว่าตนมิได้มีการกระทำใด ๆ ไม่ได้ เพราะตามกฎหมายอาญาถือว่าเสือมีการกระทำแล้ว เป็นการกระทำโดยละเว้น” แม้จะมีส่วนที่ถูกคือเสืออ้างไม่ได้ว่าตนไม่มีการกระทำแต่ส่วนคำตอบที่ว่าเสือกระทำโดยละเวนนั่นเป็นคำตอบที่ผิด จึงทำให้นักศึกษาพลาดคะแนนในส่วนของการวินิจฉัยไปอย่างน่าเสียดาย

2. มีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่า การกระทำของเสือเป็นการกระทำโดยประมาท ตาม ป.อ. มาตรา 59 วรรคสี่ หรือนักศึกษาบางส่วนยังสรุปมาด้วยว่า เสือจะอ้างว่าไม่มีการกระทำไม่ได้เพราะเป็นการกระทำโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ส่มถึงแก่ความตาย กรณีคำถามข้อนี้ นักศึกษาไม่สามารถนำเอาเรื่องประมาทตาม ป.อ. มาตรา 59 วรรคสี่ มาปรับวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ เพราะการกระทำโดยประมาทผู้กระทำต้องไม่มีเจตนา เพียงแต่ผู้กระทำไม่ได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์เช่นนั้นหรือผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงในคำถามข้อนี้ปรากฏชัดว่า เสือต้องการกำจัดส่มอยู่แล้วและในขณะเดียวกันเสือรู้ว่าส่มกำลังขับรถตามหลังกมา เสือจึงมีเจตนาฆ่าส่ม

อย่างแน่นอน ดังนั้น การกระทำของเสือที่ไม่เปิดสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเห็นรถของตนที่จอดไว้จึงไม่ใช่การกระทำโดยประมาทตาม มาตรา 59 วรรคสี่ หากนักศึกษาวินิจฉัยว่าเสือมีการกระทำอันเป็นการกระทำโดยประมาท หรือ วินิจฉัยว่าเสือได้กระทำโดยประมาทจนเป็นเหตุให้สมิงถึงแก่ความตายจึงไม่ถูกต้องและจะไม่ได้คะแนนในส่วนของการวินิจฉัยด้วย

3. จากข้อเท็จจริง เสือมีหน้าที่ในป้องกันผลมิให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด คือ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 11) เสือจึงต้องเปิดไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืน ถนนมืดมาก อาจมีรถอื่นขับมาแล่มองไม่เห็นและชนท้ายรถของเสือได้ แต่การที่เสือไม่เปิดไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนไว้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลคือสมิงมองไม่เห็นรถของเสือที่จอดอยู่จึงชนเข้าอย่างแรงจนเสียชีวิต เสือจึงมีเจตนากระทำโดยงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด สำหรับการตอบคำถามข้อนี้แม้ว่านักศึกษาจะไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรมาก่อนเลยก็ตาม แต่นักศึกษาต้องเข้าใจเรื่องหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ดีเพราะผู้กระทำโดยงดเว้นไม่สามารถอ้างความไม่รู้กฎหมายได้ และในเอกสารการสอนประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ได้อธิบายเนื้อหาเรื่องการกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษากฎีกาประกอบความเข้าใจไว้ด้วย คือ ฎีกาที่ 1909/2516 ดังนั้น นักศึกษาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการป้องกันผลทุกกรณี หากนักศึกษาตอบในส่วนของการวินิจฉัยว่า เสือมีการกระทำโดยงดเว้นเท่านั้นโดยไม่ได้ตอบว่าเสือมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะได้คะแนนในส่วนนี้น้อยลง (ทั้งนี้ นักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องตอบว่าเป็นหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก็ได้)

สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ำกับนักศึกษาว่า ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 เป็นชุดวิชาพื้นฐานของการเรียนกฎหมาย ในช่วงปีแรก นักศึกษาจึงควรเตรียมความพร้อมและฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยให้ดี ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากเอกสารโสตทัศนประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 วารสารฉบับพิเศษของสาขาวิชารวมทั้งการไปเข้ารับการสอนเสริมซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ทุกครั้งก็จะช่วยให้นักศึกษาทราบวิธีการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยที่ถูกต้องและยังได้ฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยอีกด้วย



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชา

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายดำไม่พอใจที่รู้ว่านางสาวแดงคนรักของตนไปมีคนรักใหม่ เมื่อนายดำมองที่เตียงนอนของตน ที่ตนเคยพานางสาวแดงมานอนด้วยก็ยิ่งโมโห นายดำจึงจุดไฟเผาที่นอนและเตียงนอนของตน ไฟได้ลุกลามไหม้ห้องนอนของนายดำ และทำท่าว่าจะลุกลามไปไหม้บ้านของนายเขียวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้าน แต่นายเขียวและเพื่อนบ้านคนอื่นได้ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทัน ไฟจึงไม่ไหม้บ้านของนายเขียว ดังนี้ นายดำต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 220) บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายดำไม่พอใจที่รู้ว่านางสาวแดงแฟนสาวของตนไปมีแฟนใหม่ เมื่อนายดำมองไปที่เตียงนอนของตนที่เคยพานางสาวแดงมานอนด้วยก็ยิ่งโมโห นายดำจึงจุดไฟเผาที่นอนและเตียงนอนของตน ถือว่านายดำได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของตนเอง ไฟได้ลุกลามไหม้ห้องนอนของนายดำ และทำท่าว่าจะลามไปไหม้บ้านนายเขียวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน กรณีนี้เห็นได้ว่าการทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของนายดำเองนั้น น่าจะเป็นอันตรายแก่บ้านของนายเขียวซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นแล้ว แม้ว่านายเขียวและเพื่อนบ้านคนอื่นได้ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันก็ตาม

ดังนั้น นายดำจึงมีความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ ถามว่านายดำต้องรับผิดทางอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด แต่นักศึกษาหลายคนไปตอบว่าไม่ต้องรับผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่น ตามมาตรา 217 เพราะทรัพย์สินที่เผาไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้อื่น แม้สิ่งที่ตอบจะถูกแต่นักศึกษาไม่ได้คะแนน เพราะข้อสอบข้อนี้มีฐานความผิดที่เป็นธงคำตอบอยู่แล้ว แต่นักศึกษาไม่ตอบ กลับไปตอบสิ่งที่ไม่ได้ถาม ซึ่งทำให้นักศึกษาเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้

ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนตอบว่าผิดฐานประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ ทั้งๆ ที่โจทก์บอกชัดเจนว่านายดำมีเจตนาเผาเตียงนอนซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเองไม่ได้ประมาท ส่วนการที่ไฟทำท่าจะลุกลามไปไหม้บ้านของนายเขียวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ทำให้ต้องรับผิดฐานกระทำโดยประมาทแต่อย่างใด เพราะการกระทำโดยประมาทต้องมีผลเกิด เมื่อยังไม่มีผลเกิดผู้กระทำก็ยังไม่ต้องรับผิด

นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งจะจำตัวบทไม่แม่น เอาตัวบทมาตรา 220 ไปปนกับตัวบทมาตรา 225 จนเขียนตัวบทสลับไปสลับมา ซึ่งมีผลให้เสียคะแนนหลักกฎหมายไปอย่างน่าเสียดาย นักศึกษาบางคนตอบว่าไม่ต้องรับผิดฐานใดเลย เพราะไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย เสียหายแต่ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งทำให้เห็นว่านักศึกษาอ่านหนังสือมาน้อยเกินไป จึงทำให้จำตัวบทมาตรา 220 ไม่ได้ ซึ่งถ้านักศึกษาจำตัวบทมาตรา 220 ได้ ก็จะได้รู้ว่าความผิดฐานนี้แม้เพียงน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว ไม่จำเป็นว่าบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นจะต้องเสียหาย

ดังนั้น ในการสอบครั้งต่อไปขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มากขึ้น นักศึกษาก็จะจำหลักกฎหมายได้มากขึ้น และนักศึกษาก็จะสามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่โจทก์ให้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อังครัต ดลเจิม

คำถาม

นายเขียวกับนายขาวเป็นเพื่อนกัน นายเขียวมีแฟนสาวหนึ่งคนชื่อนางสาวนุ่น วันหนึ่งทั้งสามขับรถไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างทางนายเขียวต้องการอวดว่าตนเพิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนมาใหม่ นายเขียวจึงหยิบมือถือไอโฟนของตนออกมาจากกระเป๋าทางเกง ซึ่งเมื่อนายขาวเห็นจึงพูดขึ้นว่าโทรศัพท์สวยมาก อย่างตนคงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ เมื่อนายเขียวได้ยินดังนั้นเพื่อต้องการแสดงให้นางสาวนุ่นแฟนสาวของตนเข้าใจว่าตนเป็นคนจิตใจดี จึงพูดกับนายขาวว่า “นายขาวเป็นเพื่อนรักของเรา เราขอมอบโทรศัพท์มือถือไอโฟนให้นายขาวไปใช้ เดี่ยวเราจะไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งมาใช้ในเดือนหน้า” นายขาวเมื่อฟังแล้ว จึงเข้าใจว่านายเขียวมีจิตใจดีจึงรับโทรศัพท์ไอโฟนจากนายเขียวไปใช้ ภายหลังนายเขียวมาขอให้นายขาวคืนโทรศัพท์มือถือไอโฟนให้แก่ตนโดยอ้างว่าที่ตนมอบโทรศัพท์มือถือไอโฟนให้นายขาวไปใช้เป็นแค่การแสดงให้นางสาวนุ่นแฟนสาวของตนเข้าใจว่าตนเป็นคนจิตใจดีเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วตนไม่ได้ต้องการมอบโทรศัพท์ดังกล่าวให้นายขาวแต่อย่างใด เช่นนี้ นายขาวจึงมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้ความเห็นแก่นายขาวอย่างไร จึงจะชอบด้วยกฎหมาย

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 154 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงเจตนาจะมีได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตาม หากเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆะไม่ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้น”

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการที่นายเขียวแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมการให้โทรศัพท์แก่นายขาวนั้น ภายในใจจริงนายเขียวไม่ได้ต้องการที่จะยกกรรมสิทธิ์ในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวแก่นายขาวเลย เพียงแต่ต้องการที่จะแสดงความเป็นคนจิตใจดีของตนต่อนางสาวนุ่นเท่านั้น ดังนั้นการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมดังกล่าวจึงเข้าลักษณะของการแสดงเจตนาซ่อนเร้น ตามหลักเกณฑ์ ป.พ.พ. มาตรา 154 แล้ว และในเบื้องต้นนิติกรรมดังกล่าวยังคงสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะผู้แสดงเจตนาในการทำคำสนองคือนายขาวนั้นไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของนายเขียว ดังนั้นนายเขียวจะมาขอให้นายขาวคืนโทรศัพท์มือถือแก่ตนในภายหลังไม่ได้

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเร้นซึ่งจากบทบัญญัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 154 จะเห็นได้ว่า การแสดงเจตนาซ่อนเร้นในเบื้องต้นนั้นไม่ทำให้นิติกรรมดังกล่าวนั้นตกเป็นโมฆะ นิติกรรมดังกล่าวนั้นยังคงสมบูรณ์ และยังผลให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคงมีสิทธิและหน้าที่ตามนิติกรรมนั้นทุกประการ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายจะได้ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงนั้น จึงจะส่งผลให้นิติกรรมที่คู่กรณีกระทำขึ้นนั้นตกเป็นโมฆะ และผลของการที่นิติกรรมตกเป็นโมฆะ ย่อมทำให้นิติกรรมนั้นสูญเปล่า เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น และคู่กรณีแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องผูกพันตามนิติกรรมนั้นต่อไป

จากโจทย์เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากรณีที่นายเขียวแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมการให้โทรศัพท์แก่นายขาวนั้นภายในใจจริงๆ นายเขียวไม่ได้ต้องการที่จะยกกรรมสิทธิ์ในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวแก่นายขาวเลย เพียงแต่ต้องการที่จะแสดงความเป็นคนจิตใจดีของตนต่อนางสาวบุ๋มเท่านั้น ดังนั้นการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมดังกล่าวจึงเข้าลักษณะของการแสดงเจตนาซ่อนเร้น ตามหลักเกณฑ์ ป.พ.พ. มาตรา 154 แล้ว และในเบื้องต้นนิติกรรมดังกล่าวยังคงสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะผู้แสดงเจตนาในการทำค้ำนองคือนายขาวนั้นไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของนายเขียว ดังนั้นนายเขียวจะมาขอให้นายขาวคืนโทรศัพท์มือถือแก่ตนในภายหลังไม่ได้

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดและการแสดงเจตนาซ่อนเร้นถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงในใจเช่นกัน แต่การแสดงเจตนาดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันในเบื้องต้นกล่าวคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดนั้นเป็นการแสดงเจตนาซึ่งผู้แสดงเจตนาถือว่าเจตนาที่แสดงออกมานั้นตรงกับเจตนาที่แท้จริงในใจของตน แต่ปรากฏว่าเจตนาที่แสดงออกมากลับไม่ตรงกับเจตนาอันแท้จริงในใจ เป็นเรื่องของ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิด ดังนั้น ในการศึกษาในลำดับต่อไปนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาบริบทของหลักกฎหมายตลอดจนตรวจสอบว่าในหลักกฎหมายเรื่องนั้นมีข้อยกเว้นหรือไม่ หากมีข้อยกเว้นควรศึกษาว่ากฎหมายในเรื่องนั้นมีหลักการอย่างไรบ้างจึงจะทำให้ นักศึกษาทำความเข้าใจมาตรานั้น เรื่องนั้น ได้อย่างถูกต้อง



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นายแดงเป็นลูกจ้างของนายดำมีหน้าที่ขับรถขนถ่ายไปส่งของให้แก่ลูกค้าต่างจังหวัด เมื่อส่งของเสร็จแล้วนายแดงแวะดื่มสุราร้านอาหารข้างทางขณะขับกลับเข้าสำนักงานเกิดอุบัติเหตุชนรถของนายขาวซึ่งขับมาตามปกติด้วยความระมัดระวัง เพราะเหตุนายแดงขับรถด้วยอาการมึนเมา ดังนี้ นายขาวจะฟ้องร้องให้ใครรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของตนเองได้บ้าง

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

ป.พ.พ. มาตรา 425 บัญญัติว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น”

นายแดงเป็นลูกจ้างของนายดำได้ขับรถไปส่งของตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง และเมื่อส่งของเสร็จแล้ว ขับรถกลับเข้าสำนักงานเกิดอุบัติเหตุชนรถของนายขาวได้รับความเสียหาย การกระทำของนายแดงแม้ว่าได้ส่งของเสร็จแล้วและกำลังขับรถกลับเข้าสำนักงาน ถือว่ายังอยู่ในระหว่างการทำงานในทางการที่จ้างอยู่ เมื่อการกระทำของนายแดงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในฐานะลูกจ้างของนายดำและเป็นการกระทำที่อยู่ในระหว่างการทำงานให้สมประโยชน์ของนายจ้าง ดังนี้ นายดำนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับนายแดงลูกจ้างต่อนายขาวด้วย

สรุป นายขาวสามารถฟ้องให้นายแดงและนายดำให้ร่วมรับผิดชอบฐานทำละเมิดต่อตนได้

ข้อสังเกต

มีนักศึกษาจำนวนมากตอบว่านายขาวสามารถฟ้องนายจ้างคือ นายดำได้คนเดียว และให้นายดำ นายจ้างไปไล่เบี้ยเอาค่าปลุกจ้างได้ต่อไป นักศึกษาควรอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ถามว่า นายขาวจะฟ้องร้องให้ใครรับผิดชอบได้บ้าง นักศึกษาจะต้องตอบโดยยกการกระทำละเมิดของนายแดงซึ่งเป็นลูกจ้างมาก่อน ซึ่งนายแดง ต้องรับผิดชอบในทางละเมิดตามมาตรา 420 อยู่แล้ว และการที่นายแดงเป็นลูกจ้างของนายดำซึ่งได้กระทำการ ไปในทางที่นายจ้างด้วยแล้ว กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างของตนเองด้วยในผลแห่ง ละเมิดที่ลูกจ้างได้ทำไปในทางที่จ้างนั้นด้วย ดังนั้น นายขาวจึงสามารถฟ้องทั้งนายแดงลูกจ้างและนายดำ นายจ้างให้ร่วมรับผิดชอบทางละเมิดต่อตนได้ ไม่ใช่ฟ้องนายดำซึ่งเป็นนายจ้างได้คนเดียว



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน

อาจารย์จตุรนต์ บุณยธนะ

คำถาม

อ้วนทำหนังสือสัญญากู้เงินอุด 300,000 บาท กำหนดชำระภายใน 1 ปี โดยอ้วนได้นำนาฬิกาของตน 1 เรือน และอ่วมได้นำแหวนเพชรของตน 1 วงมาจำนำไว้กับอู๊ดเพื่อเป็นประกันหนี้ดังกล่าว แต่อู๊ดเห็นว่านาฬิกาและแหวนเพชรที่อ้วนและอ่วมนำมาจำนำกับตนนั้นมีมูลค่าไม่พอกับหนี้ตามสัญญาเงินกู้ อู๊ดจึงเรียกร้องให้อ้วนหาหลักประกันเพิ่ม เมื่ออู๊ดเพื่อนสนิทของอ้วนทราบเรื่องจึงมาพบอู๊ดและตกลงคำประกันการชำระหนี้เงินกู้นั้น แต่เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ อ้วนไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ได้จึงปฏิเสธการชำระหนี้ ทำให้อู๊ดไม่พอใจเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้อู๊ดรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาจำนำประกัน เช่นนี้ หากอู๊ดต้องการเกี่ยงให้อู๊ดไปบังคับจำนำเอาจากนาฬิกาของอ้วนและแหวนเพชรของอ่วมก่อน

ให้วินิจฉัยว่า อู๊ดจะทำตามความต้องการของตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 686 บัญญัติว่า “ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้จำประกัน ชำระหนี้ได้แต่นั้น”

มาตรา 690 บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดไว้เป็นประกันไซ้ร เมื่อผู้จำประกันร้องขอ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน”

กรณีตามปัญหา อ้วนทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอุดจำนวน 300,000 บาท โดยอ้วนนำนาฬิกาของตน และอ่วมนำแหวนเพชรของตนมาจำนำไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีอู๊ดทำสัญญาจำนำประกันการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ อ้วนไม่ชำระหนี้นั้น อ้วนยอมตกเป็นผู้ผิดนัดอู๊ดในฐานะเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องให้อู๊ดผู้จำประกันรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686

ผู้จำประกันมีสิทธิเกี่ยงหรือร้องขอให้เจ้าหนี้ซึ่งมีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดไว้เป็นประกันบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันนั้นก่อนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 690 เช่นนี้แล้ว อู๊ดย่อมมีสิทธิเกี่ยงให้อู๊ดบังคับจำนำเอาจากนาฬิกาของอ้วนที่อู๊ดยึดไว้เป็นประกันนั้นก่อนได้ แต่อู๊ดไม่มีสิทธิเกี่ยงให้อู๊ดบังคับจำนำเอาจากแหวน

เพชรของอ่วม เพราะแหวนเพชรนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ แม้อึดจะได้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้นั้นก็ตาม

สรุป อึดสามารถทำตามความต้องการของตนโดยเกี่ยงให้อึดไปบังคับจำนำเอาจากนาฬิกาของอ่วนก่อนได้ แต่ไม่สามารถเกี่ยงให้อึดไปบังคับจำนำเอาจากแหวนเพชรของอ่วมก่อนได้

วิเคราะห์

จากประเด็นที่โจทย์ถามนั้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเกี่ยงหรือเบี่ยงบ่ายของผู้ค้ำประกัน

ประเด็นแรก ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นเมื่อใด ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาต้องวินิจฉัย เพราะถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน โดยนี้ตามสัญญาค้ำประกันเป็นแต่เพียงหนี้อุปการณ์ ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สองเท่านั้น ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตามสัญญาก่อนผู้ค้ำประกันเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ และถ้าลูกหนี้ไม่ชำระเจ้าหนี้ ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันจึงเกิดขึ้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686 ซึ่งประเด็นตามโจทย์เห็นว่าอึดในฐานะเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องให้อึดผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวได้เมื่ออ่วนลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่วินิจฉัยประเด็นนี้

ประเด็นที่สอง ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเบี่ยงบ่ายหรือไม่ประการใด เมื่อความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้น กฎหมายให้สิทธิผู้ค้ำประกันที่จะเกี่ยงหรือเบี่ยงบ่ายให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 690 ซึ่งเป็นสิทธินอกเหนือจากสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 688 และ 689 กรณีตามปัญหาจะเห็นว่าเจ้าหนี้ยึดถือนาฬิกาและแหวนเพชรซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้และบุคคลภายนอกไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 690 นั้น ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากนาฬิกาของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เท่านั้น หากมีสิทธิถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันไม่ ซึ่งนักศึกษาล้วนใหญ่วินิจฉัยว่าผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากนาฬิกาและแหวนเพชรซึ่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้นักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยังไม่แม่นหลักกฎหมายพอ อ้างสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 688 และ ป.พ.พ. มาตรา 689 ซึ่งไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

นายหมากได้ร่วมกับพวกจัดตั้งบริษัทเหินอเมฆจำกัด หลังจากประชุมจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเดชได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นายเดชจึงทำหน้าที่เรียกชำระค่าหุ้นจากผู้เข้าซื้อจองซื้อหุ้นทั้งหมดเต็มจำนวนตามมูลค่าหุ้น คือมูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายหมากคัดค้านการเรียกเก็บค่าหุ้นของนายเดชว่ากระทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพราะกฎหมายให้เรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น จะเรียกเก็บเกินไม่ได้ ท่านเห็นด้วยกับข้อคัดค้านของนายหมากต่อการเรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกของนายเดชหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1110 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการบริษัท มอบการทั้งปวง ให้แก่กรรมการของบริษัท

เมื่อกรรมการได้รับการแล้วก็ให้ลงมือจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้นทั้งหลายใช้เงินในหุ้น ซึ่งจะต้องใช้เป็นตัวเงิน เรียกหุ้นหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนบอกกล่าวป่าวร้อง หรือ หนังสือชวนให้ซื้อหุ้น”

จากการที่นายหมากได้ร่วมกับเพื่อนจัดตั้งบริษัทเหินอเมฆจำกัด และได้ประชุมจัดตั้งบริษัทและได้แต่งตั้งให้นายเดชเป็นกรรมการบริษัท นายเดชซึ่งเป็นกรรมการจึงมีหน้าที่ที่ต้องเรียกให้ชำระค่าหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1110 ที่กำหนดให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกขั้นต่ำไว้ที่ร้อยละยี่สิบห้า ซึ่งหมายความว่า จะเรียกสูงกว่ายี่สิบห้าได้ แม้จะเป็นการเรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นหนึ่งร้อยก็สามารถทำได้ การที่นายหมากคัดค้านว่าการเก็บค่าหุ้นของนายเดชกรรมการเต็มมูลค่าว่าไม่ถูกต้องจึงฟังไม่ขึ้น

ดังนั้น การที่นายเดชกรรมการบริษัทเหินอเมฆจำกัดเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกเต็มมูลค่าหุ้นคือ 100 บาทนั้น จึงสามารถกระทำได้ตาม มาตรา 1110 ข้างแจ้งจึงเห็นว่าข้อคัดค้านของนายหมากฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์ข้อสอบ

นักศึกษา มักจะตอบข้อสอบผิดโดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นตามมาตรา 1110 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเรียกให้ผู้เข้าซื้อถือหุ้นใช้เงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเป็นเช่นนี้นายเดชกรรมการของบริษัทเหนือเมฆ จำกัดจึงเรียกให้ผู้จองถือหุ้นชำระค่าหุ้นได้ตั้งแต่ 25 บาท ไปจนถึง 100 บาท ได้ ดังนั้นเมื่อนายเดช กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้จองถือหุ้นชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 100 บาท จึงเรียกได้ แต่นักศึกษาจำข้อกฎหมายในการเรียกให้ชำระค่าหุ้นผิด โดยเขียนหลักกฎหมายว่าจะต้องเรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกไม่เกินร้อยละ 25 จึงปรับข้อกฎหมายผิดว่า การที่นายเดชกรรมการของบริษัทเรียกเก็บค่าหุ้น 100 บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ มากกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งนักศึกษาควรดูหลักกฎหมายให้ดีเพราะถ้าจำผิดคำตอบก็จะผิดไป



วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณนักศึกษาที่ทำให้การตรวจข้อสอบชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ที่ผ่านมาสบายอย่างยิ่ง ไม่ต้องเสียเวลาหาที่ให้คะแนน เพราะนักศึกษาจำนวนมากเขียนมาแค่ 3-4 บรรทัด แถมยังตอบคนละเรื่องเดียวกัน บวกคะแนนง่าย ใช้ 2 มือก็บวกคะแนนเสร็จ ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข อย่างไรก็ดี ดูเหมือนนักศึกษาชอบสอบวิชานี้มาก เพราะหลายคนลงทะเบียนสอบอีกครั้ง แต่อาจารย์ขอเตือนว่า นักศึกษาควรทำใจสอบให้ผ่านๆ วิชานี้เสียที อย่าต้องกลับมาสอบอีกเลยแม้จะชอบเพียงใดก็ตาม

เนื่องจากเนื้อที่วิเคราะห์ข้อสอบค่อนข้างจำกัดให้อาจารย์ลงวิเคราะห์ข้อสอบได้แค่ 2 ข้อเท่านั้น ครั้นจะเลือกข้อที่นักศึกษาทำไม่ได้ ก็มีปัญหามากเพราะนักศึกษาทำไม่ได้สักข้อ อาจารย์ก็เลยใช้วิธีสรุปปัญหาข้อสอบข้อที่ 1 ซึ่งไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลย แต่นักศึกษากลับทำไม่ได้ แล้วจึงวิเคราะห์ข้อที่ 2 และ 3 ซึ่งมีประเด็นยากนิดหน่อย

ข้อสอบข้อที่ 1 ประเด็นคือ กรณีจะยื่นคำร้องขอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีใด จะต้องยื่นต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนั้น (มาตรา 7) ความจริงแล้วศาลหลักก็คือศาลที่มีคำพิพากษาในคดีนั้นซึ่งได้แก่ศาลจังหวัดนนทบุรี แต่บังเอิญว่า คดีนี้ ศาลศาลจังหวัดนนทบุรีได้มอบให้ศาลจังหวัดราชบุรีบังคับคดีแทน เมื่อบังคับคดียังไม่เสร็จก็ต้องยื่นต่อศาลที่บังคับคดีนั้น ก็เท่านั้นเอง ปัญหาของท่านนักศึกษาสุดที่รักคือ นักศึกษาจำนวนมากไม่รู้เลยว่าในโลกนี้มีมาตรา 7 เพราะมาตรา 7 ไม่ใช่มาตราถึง ไม่ใช่มาตราเน้น อย่างไรก็ตาม มาตรานี้ต้องนำไปใช้กับชีวิตจริงมากๆเลยนะ ขอบอก ข้อสอบข้อนี้ต้องยก 2 มาตรา คือ มาตรา 4(2) และ มาตรา 7(2)

ข้อสอบข้อที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่าผู้ร้องจดทะเบียนหย่ากับผู้ตายแล้วจึงไม่ได้มีส่วนได้เสีย ผู้คัดค้านเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วของผู้ตาย และผู้คัดค้านไม่ได้เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงกันได้ โดยผู้คัดค้านยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามท้ายคำร้อง ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาตามยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ให้วินิจฉัยว่า คำพิพากษาดังกล่าวชอบหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 138 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดยางานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น”

วินิจฉัย

แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงกันได้ โดยผู้คัดค้านยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่ผู้เดียว แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลเป็นการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีเพียงบางข้อ เพราะมีประเด็นที่ศาลจำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในสำนวนแล้ววินิจฉัยถึงสิทธิและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน ดังนั้น ศาลชั้นต้นไม่อาจพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้

คำพิพากษามายอมดังกล่าวจึงไม่ชอบ (เทียบ ฎ.30/2549 หน้า 6-27)

วิเคราะห์

มาตรา 138 มีหลักง่าย ๆ ประการหนึ่งคือ ข้อที่ตกลงกันนั้นต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จากข้อเท็จจริงตามคำถามข้อนี้คือ ผู้ร้องอาจจะขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดกเพราะถ้าผู้ร้องหย่ากับเจ้ามรดกแล้วผู้ร้องก็ไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีอำนาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713 ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาลจำเป็นต้องพิจารณาก่อนจึงจะพิพากษามายอมได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาจำหลักเกณฑ์และตัวบท มาตรา 138 ไม่ได้ จึงคิดว่า เมื่อคู่ความตกลงกันแล้วศาลก็ต้องพิพากษามายอมที่คู่ความตกลงกันไป นักศึกษาบางคนลงลึกขนาดว่า ศาลไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจเลย คือเค้ายอมกันมา ศาลต้องพิพากษาไปตามนั้น กรุณากลับไปอ่านหลักเกณฑ์และท่องตัวบทก่อนสอบซ่อมด้วยค่ะ
2. นักศึกษาหลายคนทีเดียว ไปตีความว่า คดีไม่มีข้อพิพาท คู่ความตกลงกันไม่ได้ เซยมากเกินไป ประสมองใหม่นะคะ คดีไม่มีข้อพิพาท ซึ่งมีผู้คัดค้านเข้ามาในคดี ทำให้ต้องดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาท คู่ความก็อาจตกลงยอมความในศาลได้ แต่ถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทซึ่งไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านเข้ามาเลย มีคู่ความฝ่ายเดียว อันนี้ ตกลงยอมความในศาลไม่ได้ เพราะไม่รู้จะยอมกับใคร

3. นักศึกษาอีกหลายคน อาจารย์เข้าใจว่าคงอ่านเอกสารการสอนจบแค่เล่ม 1 จึงไม่รู้ว่าการตกลงยอมความในศาลคืออะไร อีกทั้งไม่รู้เรื่องการพิพากษตามยอมเลย (รู้เพียงสามา) พยายามอธิบายว่า ศาลมีหน้าที่ต้องไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันตามมาตรา 19 ไม่ว่าจะอยู่ชั้นใดของศาล ถ้าไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันได้ก็ต้องพิพากษา ฉะนั้น คำพิพากษตามยอมจึงชอบด้วยกฎหมายเพราะศาลปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย (สำนวนประมาณนี้) เนื่องจากมีหลายคนเขียนถึง อาจารย์ก็เลยต้องยกมาชี้ประเด็นให้เห็นว่า มาตรา 19 เป็นเรื่องที่ศาลต้องไกล่เกลี่ย ส่วนมาตรา 138 เป็นเรื่องไกล่เกลี่ยเสร็จไปแล้ว หรือยังไม่ได้ไกล่เกลี่ยเลย คู่ความก็ตกลงกันได้แล้ว ศาลก็พิพากษตามที่ตกลงกันนั้น เป็นคนละช่วง คนละตอน คนละเล่ม สรุปคือ นักศึกษาอ่านมาถึงเล่ม 1 เลยต้องเอาเล่ม 1 มาตอบ ถึงแม้คำตอบจะอยู่ในเล่ม 2 ก็ตาม ไม่ว่ากันค่ะ แค่นี้ไม่ได้คะแนนตอนซ่อมก็พยายามอ่านให้จบเล่ม 3 ก็แล้วกันค่ะ

4. ข้อสุดท้ายมีคนผิดไม่กี่คน แต่ก็มากกว่า 10 คน เป็นคำตอบที่น่ารักมาก เพราะแสดงความจริงใจอย่างชัดเจนว่า ประสงค์จะสอบซ่อมหรือลงทะเบียนใหม่แน่นอน เพราะ นักศึกษาสามารถนำมาตรา 57 เรื่องร้องสอดมาตอบได้ อย่างสบายๆ ไม่อายคนตรวจเลย กลุ่มที่นำเรื่องร้องสอดมาตอบ ถ้ารู้ว่าไม่เกี่ยว แต่ไม่มีอะไรจะตอบ เลยต้องเอาสี่ข้างเข้าถูกก็โอเคนะคะ แต่ท่านที่เข้าใจว่าต้องเป็นเรื่องร้องสอดจริงๆ ขอความกรุณากลับไปอ่านเรื่องร้องสอดเยอะๆเลย

ข้อสอบข้อที่ 3 โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทราคา 500,000 บาท อ้างว่าจำเลยฟ้องเรียกโอนมาจากผู้อื่นและรับไว้แทนโจทก์ คินให้แก่โจทก์ และให้จำเลยคืนเงินค่ายุ่งย้างที่จำเลยยกออกไปจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์ด้วย จำเลยให้การว่า นอกจากจำเลยให้การต่อไปนี้แล้วถือว่าจำเลยปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้น จำเลยมิได้รับโอนที่ดินพิพาทไว้แทนโจทก์เพราะเป็นของจำเลยเอง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายว่าจำเลยรับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้ใด ทำให้จำเลยต่อสู้คดีได้ไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ให้วินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไร และฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิ.พ.

มาตรา 84 บัญญัติว่า “ การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระทำโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนคดีนั้น เว้นแต่...

(3) ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล”

มาตรา 84/1 บัญญัติว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น...”

มาตรา 177 วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น”

มาตรา 183 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในวันขึ้นสองสถาน ให้ศาลตรวจคำคู่ความและคำแถลงของคู่ความ เทียบกันดู และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้น ส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตามคำคู่ความ ให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท”

วินิจฉัย

ข้ออ้างตามคำฟ้องและข้อเถียงตามคำให้การจะเป็นประเด็นข้อพิพาทได้นั้น คำฟ้องและคำให้การต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีจำเลยให้การปฏิเสธต้องชัดเจนและมีเหตุแห่งการปฏิเสธด้วย ถ้าไม่ให้การถึงข้อเท็จจริงส่วนใดในคำฟ้อง ต้องถือว่าจำเลยรับตามข้อเท็จจริงนั้นแล้ว ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาท นอกจากนี้ ประเด็นข้อพิพาทอาจเกิดจากการที่จำเลยต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นขึ้นใหม่มาในคำให้การก็ได้ และประเด็นข้อพิพาทมีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งฝ่ายที่กล่าวอ้างมีภาระการพิสูจน์ และที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลเป็นผู้วินิจฉัยได้เอง คู่ความไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ตามคำถาม โจทก์อ้างว่าจำเลยฟ้องเรียกโอนที่ดินมาจากผู้อื่นและรับไว้แทนโจทก์คืนให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้รับโอนที่ดินพิพาทไว้แทนโจทก์เพราะเป็นของจำเลยเอง และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่ได้บรรยายว่าจำเลยรับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้ใด เป็นการให้การปฏิเสธโดยชัดเจนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทตามมาตรา 183 วรรคหนึ่ง ว่า

1. จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทไว้แทนโจทก์หรือไม่ และ
2. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่

ประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง โจทก์จึงต้องมีการพิสูจน์ตามมาตรา 84/1

ส่วนประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลวินิจฉัยได้เองว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ คู่ความไม่มีการการพิสูจน์ในประเด็นข้อนี้

ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยต้องคืนเงินค่ายุ่งยักที่ยักยกออกไปให้แก่โจทก์นั้น จำเลยให้การเพียงว่า “นอกจากจำเลยให้การต่อไปนี้แล้วถือว่าจำเลยปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้น” เป็นคำให้การปฏิเสธโดยไม่ชัดเจนและถือว่าจำเลยยอมรับตามฟ้องโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 177 วรรคสอง และ มาตรา 84 (3) จึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทตามคำคู่ความ

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ต้องการทดสอบว่านักศึกษากำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็นหรือไม่ เมื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว ก็ต้องกำหนดภาระการพิสูจน์ได้ อาจารย์ขอสรุปหลักการกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้ค่ะ

ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยการชี้สองสถาน การชี้สองสถานก็คือมาตรา 183 ที่ศาลต้องนำคำฟ้องและคำให้การมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาว่ายังมีประเด็นอะไรที่ยังพิพาทกันอยู่ เช่น ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ 500,000 บาท แล้วไม่ชำระคืนเลยแม้แต่บาทเดียว จำเลยต่อสู้ว่า ชำระคืนหมดแล้วพร้อมดอกเบี้ยด้วยซ้ำ กรณีนี้ ประเด็นว่ากู้หรือไม่กู้ และกู้ไปเท่าไร รับกันไปแล้ว เหลือประเด็นที่ยังพิพาทกันแค่ประเด็นเดียวคือ ชำระคืนครบหรือยัง

กรณีนี้ นักศึกษาอาจสงสัยว่า จำเลยไม่ได้บอกสักหน่อยว่ากู้หรือไม่ และกู้ไปเท่าไร ทำไมศาลบอกว่าจำเลยรับแล้ว เรื่องนี้ต้องนำมาตรา 177 มาประกอบด้วยค่ะ คือ คำให้การของจำเลยต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น หรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น สรุปความว่า ถ้าจะต่อสู้ประเด็นไหน ก็ต้องชัดแจ้งว่าปฏิเสธ แค่นั้นยังไม่พอ จะปฏิเสธลอยๆไม่ได้ ต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธ ถ้าไม่มีเหตุผลก็นำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้ เช่น จำเลยต่อสู้ว่า กู้เงินโจทก์แค่ 50,000 บาทเอง ไม่ใช่ 500,000 บาทตามฟ้อง อ้าวแล้วทำไมสัญญาที่โจทก์แนบมาท้ายฟ้องมันชัดเจนว่า 500,000 บาท จำเลยต้องให้เหตุผลด้วยว่า ทำไมสัญญาระบุ 500,000 บาท ไม่ใช่ 50,000 บาท จำเลยเซ็นบนกระดาษเปล่า หรือตอนจำเลยเซ็นสัญญาจำนวนเงินแค่ 50,000 บาท แล้วโจทก์ไปแก้ที่หลังเป็น 500,000 บาท เมื่ออ้างเหตุแล้ว จำเลยก็ต้องมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่จำเลยอ้างนั้นด้วย เป็นต้น

คำถามอีกข้อคือ ใครมีภาระการพิสูจน์ นักศึกษาจำหลักนี้ได้เกือบทุกคน ดังนั้น เกือบทุกคน (ไม่ใช่ทุกคน) จึงได้คะแนนส่วนของตัวบทกฎหมาย ซึ่งมักจะเป็นมาตราเดียวที่นักศึกษามีมาตรานี้เห็นได้ (ยกเว้นแอบดูคำตอบของเพื่อนข้างๆ) คิดมาตราอื่นกันไม่ถึงเลย ทีนี้ ปัญหาหลักคือ ภาระการพิสูจน์คืออะไร

ภาระการพิสูจน์ก็คือใครกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด (เฉพาะข้อเท็จจริงนะค่ะ ไม่รวมข้อกฎหมายเพราะถือว่ากฎหมายหลักศาลรู้เอง) ฝ่ายนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อตามนั้น เช่น ฟ้องว่าจำเลยกู้เงิน โจทก์กล่าวอ้างจำเลยปฏิเสธ โจทก์ก็ต้องมีภาระการพิสูจน์ แต่บางครั้งข้อกล่าวอ้างของจำเลย คล้ายๆ ว่า จำเลยกล่าวข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ แต่ความจริงแล้ว ยังถือว่าโจทก์กล่าวอ้างอยู่ เช่น ข้อกล่าวอ้างว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะเริ่มนับอายุความผิดวัน สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอม เป็นต้น เหล่านี้โจทก์ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่ รวมถึง กรณีโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย โจทก์ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียหายเท่าไร เป็นต้น

ความสำคัญของภาระการพิสูจน์คือ หากใครมีภาระการพิสูจน์ แล้วพิสูจน์ไม่ได้ตามที่กล่าวอ้างไว้ ฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ต้องแพ้คดี

ขอให้ศึกษาย้อนกลับไปดูเฉลยข้อสอบด้านบน อาจารย์จะกล่าวถึงเฉพาะ ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ปัญหาหลักคือนักศึกษาไม่อ่านตัวบท อ่านได้แค่หลักเดียวคือ ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องพิสูจน์ กล่าวอ้างอะไรก็ไม่ระบุ บางคนไม่รู้ด้วยว่า หมายถึงกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด แล้วต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ถ้ากล่าวอ้างข้อกฎหมาย ก็ไม่ต้องพิสูจน์
2. นักศึกษาแยกไม่ออกว่า อะไรคือปัญหาข้อเท็จจริง อะไรคือปัญหาข้อกฎหมาย จำง่าย ๆ แล้วกัน ค่ะว่า ถ้าเรื่องนั้นต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานก็คือข้อเท็จจริง เช่น จำเลยขับรถมาเร็วแค่ไหน มีลักษณะการขับรถอย่างไร ขับสายไปมาหรือไม่ นี่คือข้อเท็จจริง แต่ถ้าจะต้องวินิจฉัยว่า ลักษณะการขับของจำเลยนั้นเป็นการขับรถโดยประมาทหรือไม่ อันนี้เป็นข้อกฎหมาย
3. นักศึกษาหลายคนทีเดียวที่กำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่เป็น ก็ขอให้ย้อนกลับขึ้นไปอ่านวิธีกำหนดประเด็นข้อพิพาทด้วย
4. ข้อสุดท้าย อาจารย์สะท้อนใจมาก เพราะนักศึกษาหลายคน ยกมาตรา 88 เรื่อง การยื่นบัญชีระบупยานมาตอบ ตรวจไปเชิงไป แต่เชิงที่สุดคือ หลายคนอีกเหมือนกัน ยกมาตรา 90, 93 และ 94 ซึ่งเป็นเรื่องพยานเอกสารมาตอบ ถ้าหวังว่า ชุดวิชานี้มี “คะแนนค่าน้ำหมึก” ก็ฝันไปเหอะ เลข 0 อย่างเดียวเลยล่ะ บวกง่ายด้วย สุดท้ายขอให้นักศึกษาสอบซ่อมอย่างมีความสุข สอบผ่านๆ ไปซะ เบื่อตรวจแล้วค่ะ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 :

วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์

คำถาม

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ก. คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาโดยไม่จงใจมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้ในกรณีใดบ้าง
- ข. โจทก์และจำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว โจทก์มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่

แนวตอบ

- ก.) คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาโดยไม่จงใจ มีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้ 2 กรณี คือ
1. ขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดี (ป.วิ.พ. มาตรา 206 วรรค 3) โดยในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้ว และแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะดำเนินคดีเมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดพิจารณานั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม่เคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อน
 2. ขอพิจารณาคดีใหม่หลังจากศาลพิพากษาคดีแล้ว (ป.วิ.พ. มาตรา 207) โดยเมื่อศาลพิจารณาคดีฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดแพ้อคดี
- ข.) การขอพิจารณาคดีใหม่จะทำได้เมื่อมีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวไปบ้างแล้ว แต่ถ้าไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเลยเพราะเหตุเช่นเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีก็ย่อมไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว อันจะทำให้ขอพิจารณาคดีใหม่ได้ (ฎีกาที่ 1360/2534 , เอกสารคำสอนหน้า 4-19) ฉะนั้นเมื่อโจทก์และจำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้วโจทก์และจำเลยจึงไม่อาจขอพิจารณาคดีใหม่ได้เลย สำหรับโจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีก็ไม่ได้เพราะต้องห้ามตามมาตรา 203 โจทก์ได้แต่จะฟ้องคดีใหม่ภายในกำหนดอายุความเท่านั้น

วิเคราะห์

ข้อสอบนี้ต้องการวัดผลว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องการขาดนัดพิจารณากับการขอพิจารณาคดีใหม่เพียงใด

1. หลักกฎหมาย

การขาดนัดพิจารณาต้องผ่านขั้นตอนการยื่นคำให้การมาแล้วจนศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคดีโดยนัดสืบพยานโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่จะกำหนดให้ใครนำสืบก่อน ซึ่งเรียกว่า “วันสืบพยาน” ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาในวันสืบพยานครั้งแรก คู่ความฝ่ายนั้นย่อมขาดนัดพิจารณาโดยผลของกฎหมายศาลไม่ต้องมีคำสั่งว่าคู่ความคนนั้นขาดนัดพิจารณาอีก การขาดนัดพิจารณามีเฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น

ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณา (แม้เป็นวันนัดสืบพยานจำเลย) ศาลต้องจำหน่ายคดี เว้นแต่จำเลยจะแจ้งต่อศาลว่าตนประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลจึงพิจารณาคดีฝ่ายเดียวโดยสืบพยานจำเลยไปฝ่ายเดียว (ป.วิ.พ. มาตรา 202) ถ้าจำเลยขาดนัดพิจารณา (แม้เป็นวันนัดสืบพยานโจทก์) ศาลก็พิจารณาคดีโดยสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว (ป.วิ.พ. มาตรา 204)

ถ้า 2 ฝ่ายขาดนัดพิจารณา ศาลต้องจำหน่ายคดีเท่านั้น (ป.วิ.พ. มาตรา 201)

ถ้าระหว่างพิจารณาคดีฝ่ายเดียวยังไม่เสร็จ ฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาล และแจ้งต่อศาลว่าตนประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป เมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดพิจารณานั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร ศาลก็มีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 206 วรรค 3 ซึ่งเป็นการขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดี

แต่ถ้าฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลหลังจากศาลพิจารณาคดีฝ่ายเดียวแล้วพิจารณาคดีให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดแพคดี คู่ความฝ่ายนั้นก็ย่อมขอพิจารณาคดีใหม่ได้ แต่ถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดชนะคดีก็จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

คำตอบในข้อ ก. จึงมี 2 กรณี คือ ขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลพิพากษาและขอพิจารณาคดีใหม่หลังศาลพิพากษาดังกล่าว

ส่วนหลักกฎหมายในข้อ ข. ก็คือ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีจึงไม่มีการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว โจทก์และจำเลยจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ โดยเอาหลักกฎหมายจากข้อ ก. มาตอบ

2. ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ

นักศึกษาไม่เข้าใจโดยไม่ได้ดูหนังสือมาเลยหรือดูผ่าน ๆ ทั้ง ๆ ที่ในหน่วยที่ 4 เรื่องการขาดนัดและการขอพิจารณาคดีใหม่สำคัญมากที่สุด มีการออกข้อสอบในทุกสนามสอบ สำหรับข้อบกพร่องมีดังนี้

กรณีข้อ ก.

1. นักศึกษาตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าคู่ความที่ขาดนัดพิจารณาโดยไม่จงใจ มีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้เสมอ โดยคาดเดาจากข้อเท็จจริงในข้อสอบว่าขาดนัดพิจารณาโดยไม่จงใจ

2. นักศึกษาเอาเรื่องขาดนัดยื่นคำให้การมาตอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 199, 199 ตรี ซึ่งเป็นกรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและแพ้คดีและขอพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งไม่ถูกต้อง

3. นักศึกษาตอบตามตัวบท ป.วิ.พ. มาตรา 201-202 เรื่องทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา โจทก์ขาดนัด และจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วตอบลอย ๆ ว่าขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ได้

กรณีข้อ ข.

นักศึกษาแทบจะไม่ได้ตอบเลยว่าการที่ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเท่ากับไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเลย อันจะทำให้ขอพิจารณาคดีใหม่ได้ แต่นักศึกษากลับตอบดังนี้

1. นักศึกษาตอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 203 ว่าขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 203 โจทก์ได้แต่ฟ้องคดีใหม่ในอายุความ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะคำถามถามเรื่องโจทก์ขอพิจารณาใหม่ ไม่ได้ถามว่าโจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้หรือไม่ หรือโจทก์จะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่ แต่ก็อนุโลมให้คะแนน

2. นักศึกษาบางคนตอบว่าขอพิจารณาคดีใหม่ได้ โดยฟ้องคดีเข้ามาใหม่ภายในอายุความ โดยนักศึกษาเข้าใจผิดว่า**การพิจารณาคดีใหม่กับการฟ้องคดีใหม่**เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะการฟ้องคดีใหม่คือการ**เริ่มต้นคดีใหม่** ต้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและยื่นคำให้การชี้แจงสถานสืบพยาน ฯลฯ ส่วนการพิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณาคาลยกคดีเดิมขึ้นพิจารณาใหม่ เริ่มเฉพาะขั้นตอนในวันสืบพยานเท่านั้น คือถ้ามีการสืบพยานไปครึ่งปากก็เริ่มสืบกันใหม่ **หรือ** ศาลตัดสินไปแล้วก็เริ่มต้นสืบพยานของคู่ความใหม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือยกเลิกการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว เป็นการพิจารณาคดี 2 ฝ่ายตามปกติ

3. บางคนตอบว่าขอพิจารณาคดีใหม่ได้เพราะไม่จงใจขาดนัดพิจารณา เนื่องจากยังติดขัดอยู่กับคำถาม ข้อ ก.

4. บางคนตอบว่าขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ เพราะศาลสั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว ซึ่งกำกวมไม่แน่ใจว่ารู้หรือไม่รู้ว่าการนี้จะขอพิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณาต้องมีการ**พิจารณาคดีฝ่ายเดียว**เป็นหลัก ถ้าไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

ขอให้ให้นักศึกษาจำหลักกฎหมายให้แม่นยำสอบครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาด และข้อสำคัญอีกประการคือขอให้เขียนหนังสือให้อ่านได้ง่าย อย่าเขียนจนอ่านไม่ออกจนให้คะแนนไม่ได้



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ

คำถาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ต่อมาก่อนครบกำหนดแก้อุทธรณ์ จำเลยขอถอนอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ และให้ออกหมายจำคุกจำเลย คดีถึงที่สุดในวันเดียวกัน

ให้วินิจฉัยว่า คำสั่งให้ออกหมายจำคุกจำเลยคดีถึงที่สุด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มาตรา 202 บัญญัติว่า “ผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้ เมื่อส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่ง ทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

เมื่อถอนไปแล้ว ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์ จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้น”

มาตรา 245 วรรคสอง บัญญัติว่า “ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ไปยังศาลอุทธรณ์ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น และคำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืน”

จากบทกฎหมายดังกล่าว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง กำหนดให้ศาลชั้นต้นต้องส่งสำนวนที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตจำเลย ไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง แม้จะไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้นก็ตาม ส่วนการถอนอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคหนึ่ง มีผลปลั้งการยื่นอุทธรณ์เสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นอุทธรณ์เลย การที่จำเลยในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ต่อมาได้ขอถอนอุทธรณ์นั้นเสีย ย่อมต้องถือว่ามีผลเท่ากับจำเลยนั้นมิได้ยื่น

อุทธรณ์เลย ต้องบังคับให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง เหมือนเช่นกรณีที่จำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทุกประการ และคำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืน จะบังคับผลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคสอง ที่ว่าคดีของจำเลยผู้ถอนอุทธรณ์เป็นอันเด็ดขาดแล้วมิได้

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จำเลยขอถอนอุทธรณ์ก่อนครบกำหนดแก้อุทธรณ์ แสดงว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์ก่อนส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคหนึ่ง ย่อมเกิดผลตามมาก็คือลบล้างการยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเสมือนไม่มีการยื่นอุทธรณ์เลย แต่เนื่องจากศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต กรณีจึงต้องด้วย มาตรา 245 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่กำหนดให้ศาลชั้นต้นต้องส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์พิจารณา และคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษายืน

ดังนั้น ต้องถือว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นยังไม่ถึงที่สุด คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ออกหมายจำคุกจำเลยคดีถึงที่สุดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ คำสั่งให้ออกหมายจำคุกจำเลยคดีถึงที่สุดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง คำสั่งให้ออกหมายจำคุกจำเลยคดีถึงที่สุด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นักศึกษาควรยกหลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถาม กล่าวคือ ผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคหนึ่ง และศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ไปยังศาลอุทธรณ์ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง

ประการที่สอง ประเด็นคำถามในเรื่องนี้มีประเด็นย่อยที่ต้องอธิบายและวินิจฉัยเป็นลำดับ คือ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคหนึ่ง ประการต่อมา การถอนอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคหนึ่ง มีผลลบล้างการยื่นอุทธรณ์เสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นอุทธรณ์เลย ประการสุดท้าย คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ศาลชั้นต้นต้องส่งสำนวนดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนไม่สามารถตอบคำถามได้ เนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประเด็นสำคัญเรื่องนี้เป็น คำพิพากษาของศาลชั้นต้นถึงที่สุดหรือไม่ แต่มีนักศึกษาหลายคนหลงประเด็นไปตอบเรื่องเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่

ประการที่สี่ มีนักศึกษาบางส่วนจับประเด็นปัญหาได้ แต่ไม่สามารถตอบคำถามได้ เพราะไม่ทราบว่าให้นำบทบัญญัติมาตราใดมาตอบ จึงตอบว่าคดีถึงที่สุดเพราะได้มีการถอนอุทธรณ์แล้ว หรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 วรรคสอง

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้เลย เพราะไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 และมาตรา 245 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การขอถอนอุทธรณ์คำพิพากษาและผลของการถอนอุทธรณ์ อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

หนึ่งเข้าทำกินในที่ดินมีโฉนดของสอง โดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า มาเป็นเวลา 4 ปี จึงรู้ว่าที่ดินนั้นเป็นของสอง หนึ่งกลัวว่าจะมีปัญหาจึงขายที่ดินนั้นให้สาม โดยสามไม่ทราบเรื่องความเป็นมา สามทำกินในที่ดินนั้นต่อมาเป็นเวลา 7 ปี สองเจ้าของที่ดินตามโฉนดจึงทราบเรื่องและได้แจ้งให้สามออกจากที่ดินดังกล่าวมิฉะนั้นจะฟ้องร้องดำเนินคดี เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า สามจะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซ้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”

มาตรา 1385 บัญญัติว่า “ถ้าโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ ถ้าผู้รับโอนนับรวมเช่นนั้น และถ้ามีข้อบกพร่องในระหว่างครอบครองของผู้โอนไซ้ ท่านว่าข้อบกพร่องนั้นอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้”

ตามปัญหา หนึ่งเข้าทำกินในที่ดินมีโฉนดของสอง โดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลา 4 ปี จึงเห็นได้ว่าหนึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ดังกล่าว ต่อมาหนึ่งได้ขายที่ดินนั้นให้แก่สามโดยสามไม่ทราบเรื่องความเป็นมา สามได้ทำกินในที่ดินนั้นต่อมาเป็นเวลา 7 ปี เป็นการโอนการครอบครองแก่กัน สามผู้รับโอนจึงนับเวลาซึ่งหนึ่งผู้โอนการครอบครองอยู่ก่อนนั้น รวมเข้ากับเวลาการครอบครองของตนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1385 ดังกล่าว เมื่อรวมเวลาการครอบครองดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี สามจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

ฉะนั้น สามจึงมีข้อต่อสู้ว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว

วิเคราะห์

การโอนการครอบครองนั้น นับเวลาการครอบครองรวมต่อเนื่องกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1385 นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่หลงลืมหลักกฎหมายในบทบัญญัตินี้ ทำให้วินิจฉัยคำตอบผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป

คำถาม

นายเจเนภาพครอบครองและปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่งของนางสาวมุตตามากกว่า 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ต่อมานางแจงจิตได้จดทะเบียนซื้อที่ดินนั้นโดยสุจริตจากนางสาวมุตตา นางแจงจิตมิได้เข้าครอบครองที่ดินด้วยเกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับนายเจเนภาพจึงปล่อยให้นายเจเนภาพครอบครองที่ดินนั้นต่อไป และนายเจเนภาพก็ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านนางแจงจิตเลย หลังจากนั้นอีก 10 ปี นางแจงจิตถึงแก่ความตาย นางสาวเข็มทอง บุตรสาวของนางแจงจิตผู้จดทะเบียนรับมรดกที่ดินนั้นมาฟ้องขับไล่นายเจเนภาพ นายเจเนภาพต่อสู้ว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่านางสาวเข็มทอง ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายเจเนภาพฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไว้ ท่านว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว”

มาตรา 1382 บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซ้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”

วินิจฉัยตามปัญหา นายเจเนภาพครอบครองและปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่งของนางสาวมุตตามากกว่า 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อนายเจเนภาพมิได้จดทะเบียนสิทธิของตน ย่อมไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ตามมาตรา 1299 วรรคสอง ป.พ.พ. ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางแจงจิตได้จดทะเบียนซื้อที่ดินนั้นโดยสุจริตจากนางสาวมุตตา เช่นนี้แล้ว นายเจเนภาพมิอาจยกสิทธินั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้นางแจงจิตได้ ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า นางแจงจิตกลับปล่อยปละให้นายเจเนภาพครอบครองที่ดินนั้นต่อไปเป็นเวลาอีก 10 ปี จนกลายเป็นการครอบครองปรปักษ์ต่อนางแจงจิตต่อมาอีก ตามมาตรา 1382 ป.พ.พ. นายเจเนภาพย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม และยกขึ้นต่อสู้นางแจงจิตได้ ตามมาตรา 1299 วรรคสอง ป.พ.พ. (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2595/2541) เมื่อนางแจงจิตถึงแก่ความตาย นางสาวเข้มทองบุตรสาวของนางแจงจิตจดทะเบียนรับมรดกที่ดินนั้นมา เช่นนี้ นางสาวเข้มทองไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ตามมาตรา 1299 วรรคสอง ป.พ.พ. จึงไม่อาจฟ้องขับไล่นายเจนภาพได้ การที่นายเจนภาพต่อสู้ว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่านางสาวเข้มทองจึงฟังขึ้น

สรุป ข้อต่อสู้ของนายเจนภาพฟังขึ้น

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ ตอนแรก นายเจนภาพครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนางสาวมุตตาจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 แต่ยกเป็นข้อต่อสู้นางแจงจิตบุคคลภายนอกผู้จดทะเบียนรับโอนโดยสุจริตไม่ได้ แต่ในตอนหลังนายเจนภาพได้ครอบครองที่ดินของนางแจงจิตต่อมาจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์อีกครั้งหนึ่ง นางสาวเข้มทองลูกสาวของนางแจงจิตเป็นผู้สืบสิทธิของนางแจงจิตจึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดก นายเจนภาพยกการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้นางแจงจิตได้ก็ย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นางสาวเข้มทองผู้สืบสิทธิได้เช่นเดียวกัน นักศึกษาวิเคราะห์ไม่ละเอียด ทำให้วินิจฉัยผิดพลาดไป



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล

คำถาม

นายเดวิดเป็นบุตรของนายจอห์นบิดาซึ่งมีสัญชาติอังกฤษ และ นางโซฟี มารดาซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศส แต่นายเดวิดเกิดที่ประเทศไทย เนื่องจากนายจอห์นและนางโซฟี ได้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจตั้งภัตตาคารฝรั่งเศสในประเทศไทย ครอบครัวนี้ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปี เมื่อนายเดวิดอายุ 16 ปี ได้หลงรักนางสาวดวงใจเพื่อนร่วมชั้นเรียนและได้ทำพินัยกรรมยก ทรัพย์สินทั้งหมดของตนให้นางสาวดวงใจ โดยเขียนพินัยกรรมทั้งฉบับด้วยตนเอง ซึ่งนายเดวิดมีเงินเก็บอยู่ในธนาคาร 100,000 บาท และ เป็นเจ้าของตึกแถวหนึ่งคูหา ราคา 1,000,000 บาท ซึ่งนายจอห์นยกให้นายเดวิดเป็นของขวัญวันเกิดเมื่ออายุครบ 15 ปี ต่อมานายเดวิดประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย นางสาวดวงใจจึงมาเรียกร้องทรัพย์สินมรดกจากบิดา มารดา นายเดวิด แต่นายจอห์นและ นางโซฟี ปฏิเสธที่จะดำเนินการยกทรัพย์สินให้ โดยอ้างว่าตามกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส บุคคลจะทำพินัยกรรมได้ต้องอายุ ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และ พินัยกรรมต้องทำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นพินัยกรรมที่นายเดวิดทำจึงเป็นโมฆะ เนื่องจากนายเดวิดไม่มีความสามารถในการทำพินัยกรรมอีกทั้งไม่ได้ทำพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายกำหนดพินัยกรรมจึงเป็นโมฆะ นักศึกษาจงพิจารณา วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายจอห์นและนางโซฟี ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ไม่ และ นางสาวดวงใจจะได้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม หรือ ไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ. ศ. 2508, แก้ไข 2535, และแก้ไข 2551

มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

- (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
- (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมาย หรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

- (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
- (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรือ

(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
มาตรา 8 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาติไทย ถ้า
ขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น

- (1) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
- (2) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล
- (3) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
- (4) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาอยู่กับ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

มาตรา 6

.....
ในกรณีใดๆ ที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของบุคคล ถ้าสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดซึ่งขัดกันนั้นเป็น
สัญชาติไทย กฎหมายสัญชาติซึ่งจะใช้บังคับได้แก่กฎหมายแห่งประเทศสยาม

มาตรา 39 ความสามารถของบุคคลที่จะทำพินัยกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติในขณะที่ทำ
พินัยกรรม

มาตรา 40 บุคคลจะทำพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายสัญชาติกำหนดไว้ก็ได้ หรือจะทำตามแบบ
ที่กฎหมายของประเทศที่ทำพินัยกรรมกำหนดไว้ก็ได้

มาตรา 41 ผลและการตีความพินัยกรรมก็ดี ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ก็ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายมูลำเนาของผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ยุติพินัยกรรมถึงแก่ความตาย

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

มาตรา 25 ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 15 ปีบริบูรณ์

มาตรา ๒๒ ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือ
เป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง ย่อมสามารถทำได้

มาตรา 1657 พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียน
ด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน

วินิจฉัย

ประเด็นปัญหา

1. นายเดวิดมีสัญชาติใด
2. มูลพิพาทเกี่ยวกับเรื่องใด

3. ต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับกับคดี
4. ความสามารถในการทำพินัยกรรม และ แบบของพินัยกรรมบังคับตามกฎหมายประเทศใด และมีแบบอย่างไร
5. ปัญหาการตีความ หรือ การมีผลของพินัยกรรมใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ

1. นายเดวิดเป็นบุตรของนายจอห์นบิดาซึ่งมีสัญชาติอังกฤษ และ นางโซฟี มารดาซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศส แต่นายเดวิดเกิดที่ประเทศไทย โดยนายจอห์นและนางโซฟี ได้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจตั้งภัตตาคารฝรั่งเศสในประเทศไทย ครอบครัวนี้ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปี นายเดวิดจึงมีสัญชาติอังกฤษและฝรั่งเศสตามหลักสืบสายโลหิต และได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง เพราะแม้บิดามารดาจะเป็นต่างด้าวทั้งคู่ แต่ครอบครัวนี้ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้ง 20 ปี จึงไม่ใช่บุคคลที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว หรือ ไม่ได้เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบ หรือ ไม่ได้เข้าเมืองมาอยู่โดยได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้เข้ามาประกอบธุรกิจทำภัตตาคารฝรั่งเศสโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง บิดา มารดา ของเดวิดไม่ได้ เป็นบุคคลในคณะทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ คนใช้ หรือ ครอบครัวทูต เดวิดจึงมีสัญชาติไทยด้วย และเดวิดเป็นบุคคลมีสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปอันได้รับมาคราวเดียวกันคือสัญชาติ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ สัญชาติไทย

2. มูลพิพาทในคดีนี้เกี่ยวกับความสามารถในการทำพินัยกรรม และแบบของพินัยกรรม เนื่องจาก บิดา มารดานายเดวิด อ้างว่า นายเดวิดไม่มีความสามารถทำพินัยกรรมด้วยยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ตามกฎหมายไทยนายเดวิดสามารถทำพินัยกรรมได้ อีกทั้งแบบของพินัยกรรมของประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสก็แตกต่างจากแบบของพินัยกรรมตามกฎหมายไทย ดังนั้นเมื่อมีมูลพิพาทกันด้วยความสามารถในการทำพินัยกรรมและแบบของพินัยกรรมซึ่งนายเดวิดมีหลายสัญชาติรวมทั้งสัญชาติไทยด้วยจึงจะใช้กฎหมายไทยแทนที่ไม่ได้ เนื่องจากเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติ (Foreign Elements)

3. คดีที่พิพาทกันด้วยเรื่องความสามารถในการทำพินัยกรรมและแบบของพินัยกรรมซึ่งเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติดังกล่าว จึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันอันเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดี ซึ่ง มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน บัญญัติว่าความสามารถของบุคคลที่จะทำพินัยกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติในขณะที่ทำพินัยกรรม จึงต้องหาสัญชาติของนายเดวิดเพื่อหากฎหมายสัญชาติมาปรับใช้กับคดี และ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน บัญญัติว่าในกรณีใดๆ ที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของบุคคล ถ้าสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดซึ่งขัดกันนั้นเป็นสัญชาติไทย กฎหมายสัญชาติซึ่งจะใช้บังคับได้แก่กฎหมายแห่งประเทศสยาม ดังนั้นนายเดวิดซึ่งมีหลายสัญชาติแต่มีสัญชาติไทยอยู่ด้วยจึงต้องใช้สัญชาติไทยในการหากฎหมายมาบังคับกับคดี

4. ดังนั้นเมื่อหากฎหมายแห่งสัญชาตินายเดวิดได้แล้วคือ กฎหมายไทย จึงสามารถพิจารณาความสามารถตามกฎหมายไทยต่อไป รวมทั้งแบบของพินัยกรรม ซึ่งมาตรา 25 ปพพ บัญญัติว่า ผู้เยาว์อาจทำ

พินัยกรรมได้เมื่ออายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน บัญญัติว่า บุคคลจะทำพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายสัญชาติกำหนดไว้ก็ได้ หรือจะทำตามแบบที่กฎหมายของประเทศที่ทำพินัยกรรมกำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นเดวิดซึ่งมีสัญชาติไทยและทำพินัยกรรมในประเทศไทยจึงสามารถทำพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายไทยกำหนดได้ และ แบบของพินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย หากทำตามแบบที่กฎหมายไทยกำหนด เมื่อพิจารณาแบบของพินัยกรรมตามกฎหมายไทยอันเป็นกฎหมายสัญชาติของเดวิดและที่ ที่ทำพินัยกรรม จะพบว่า กฎหมายไทยบัญญัติแบบของพินัยกรรมไว้หลายแบบ รวมทั้งแบบเขียนเองทั้งฉบับได้ตาม มาตรา 1657 พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน ดังนั้นนายเดวิดจึงทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับได้และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย

5. เกี่ยวกับปัญหาการตีความ หรือ การมีผลของพินัยกรรมใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน บัญญัติว่า ผลและการตีความพินัยกรรมก็ดี ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมก็ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายภูมิลำเนาของผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย ดังนั้นนายเดวิดมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยในขณะที่ถึงแก่ความตายจึงต้องใช้กฎหมายไทยบังคับกับคดี

สรุป

1. นายเดวิดมีสัญชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส และ ไทย
2. มูลพิพาทในคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการทำพินัยกรรมซึ่งต้องใช้กฎหมายสัญชาติมาบังคับกับคดี และ แบบของพินัยกรรม ซึ่งสามารถทำตามแบบกฎหมายสัญชาติ หรือ ตามแบบกฎหมายของประเทศที่ทำพินัยกรรม นั่นคือกฎหมายไทย
3. ต้องใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับกับคดี เมื่อนายเดวิดเป็นบุคคลที่มีหลายสัญชาติที่ได้มาในเวลาเดียวกัน แต่นายเดวิดมีสัญชาติไทยด้วย กฎหมายขัดกันของไทย ให้ใช้กฎหมายสยามเป็นกฎหมายสัญชาติที่จะมาบังคับกับคดี
4. นายเดวิดมีความสามารถในการทำพินัยกรรม ซึ่งตามกฎหมายไทยผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ แบบของพินัยกรรมบังคับตามกฎหมายประเทศไทยได้เพราะเป็นกฎหมายสัญชาติของผู้ทำพินัยกรรม และ แบบของพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเป็นแบบของพินัยกรรมที่สามารถทำได้ตามกฎหมายไทยได้โดยสมบูรณ์
5. ส่วนปัญหาการตีความ หรือ การมีผลของพินัยกรรมให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับกับคดี
6. ดังนั้นนางสาวดวงใจจึงสามารถรับมรดกตามพินัยกรรมได้ แม้นางสาวดวงใจจะเป็นผู้เยาว์แต่การทํานิติกรรมตาม มาตรา ๒๒ ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้อำนาจสิทธิ์อันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง ย่อมสามารถทำได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถวิเคราะห์ประเด็นโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับการกำหนดสัญชาติได้หรือไม่ และสามารถวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีได้หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน ในเรื่องการหาสัญชาติของบุคคล การหากฎหมายสัญชาติที่จะมาบังคับกับคดี และ การวิเคราะห์มูลคดีพิพาท ตลอดจนการปรับใช้กฎหมายไทยบังคับกับคดีได้ถูกต้องหรือไม่ เป็นการศึกษาอย่างบูรณาการในการใช้กฎหมาย ซึ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

จุดบกพร่องที่นักศึกษาไม่สามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ มีตั้งแต่การไม่ได้ศึกษามาอย่างเพียงพอ ยังไม่เข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด รวมทั้งไม่มีความรู้กฎหมายไทยด้วย นักศึกษาไม่ได้คิด วิเคราะห์ให้รอบด้าน นักศึกษาเกือบทั้งหมดไม่ได้ตอบเกี่ยวกับการหาสัญชาติของบุคคลที่มีหลายสัญชาติ และ การหากฎหมายสัญชาติมาบังคับกับคดี ส่วนใหญ่มักจะรวบรัดตอบว่า นายเดวิดเป็นคนไทยและใช้กฎหมายไทยบังคับไปทันที ทำให้ไม่ได้ตอบครอบคลุมทุกด้าน จึงแนะนำให้นักศึกษาฝึกการ คิด วิเคราะห์เป็นระบบ รอบด้าน ศึกษาโจทย์ที่ถามมาให้ละเอียด ทุกประเด็น แล้วกำหนดประเด็นคำถาม แล้วจึงวางหลักกฎหมายให้ครบถ้วน และวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายที่ได้วางไว้ นักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม และเป็นขั้นตอน ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนแล้วสำรวจความผิดพลาดในการทำสอบของตนเองแล้วแก้ไขให้ดีขึ้น ย่อมประสบความสำเร็จในการสอบ

คำถาม

นาย โมฮัมหมัด ชาวโรฮิงยา ต้องการหนีออกจากประเทศพม่า โดยบุกขึ้นไปจีเครื่องบินสายการบินแควนตัสที่จอดอยู่ที่สนามบินกรุงย่างกุ้ง แล้วบังคับนายปีเตอร์ ซึ่งมีสัญชาติอังกฤษ และเป็นกัปตันเครื่องบินดังกล่าวให้ไปส่งที่ประเทศสิงคโปร์ แต่นายปีเตอร์ขัดขืนจึงถูกนายโมฮัมหมัด ยิงบาดเจ็บ นางสาวมิชิโกะ แอร์โฮสเตส สัญชาติญี่ปุ่น ที่ทำงานในเครื่องบินดังกล่าว เข้าช่วยเหลือกัปตัน จึงถูกยิงบาดเจ็บอีกคน นายโมฮัมหมัด ได้บังคับให้กัปตันที่สองนำเครื่องบินลงจอดที่ปาปัวนิวกินีแทน แล้วหลบหนีไป ต่อมา นายโมฮัมหมัดได้รับแจ้งจากเพื่อนๆ ให้ทราบว่าคนไทยใจดีเลี้ยงดูชาวโรฮิงยาอย่างดี ไม่ต้องหนีไปไหนให้มาปักหลักที่ประเทศไทยจะดีกว่า นายโมฮัมหมัด ดีใจมากจึงลี้ภัยหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่ถูก ตำรวจของไทยจับตัวได้ ดังนี้ นักศึกษาจงพิจารณาว่า

1. ประเทศไทยมีเขตอำนาจรัฐในการดำเนินคดีจีเครื่องบินกับนายโมฮัมหมัดได้
2. ประเทศไทยมีเขตอำนาจรัฐที่จะดำเนินคดีต่อนายโมฮัมหมัดได้หรือไม่เพราะเหตุใด
3. หากประเทศออสเตรเลียจะร้องขอให้รัฐบาลไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังออสเตรเลียจะได้หรือไม่ หากประเทศไทยและออสเตรเลียมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

เขตอำนาจรัฐ หมายถึง อำนาจตามกฎหมายของรัฐเหนือ บุคคล ทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหากพิจารณาเขตอำนาจรัฐในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของอธิปไตยของรัฐ แล้ว อาจแบ่งเขตอำนาจรัฐออกเป็น เขตอำนาจในทางนิติบัญญัติ เขตอำนาจในทางศาล และเขตอำนาจในการบังคับการตามกฎหมายในทางบริหาร แต่หากคำนึงถึงประโยชน์ในการทำความเข้าใจขอบเขตของเขตอำนาจรัฐ อาจจำแนกเขตอำนาจของรัฐออก ดังนี้

- 1) เขตอำนาจในการสร้างหรือบัญญัติกฎหมาย โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
- 2) เขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยฝ่ายตุลาการ และโดยฝ่ายบริหาร

การใช้เขตอำนาจรัฐ ในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยได้มีการศึกษาสำรวจทางปฏิบัติของรัฐต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พบว่าการใช้เขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคล ทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น มีมูลฐาน (Basis) เนื่องจากหลักการ (principle) 5 ประการ ที่สนับสนุนการใช้เขตอำนาจของรัฐด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ได้แก่

1. หลักดินแดน (Territorial Principle) หมายถึง รัฐมีเขตอำนาจเหนือบุคคล ทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในดินแดนของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่า บุคคลนั้นมีสัญชาติของรัฐใด หรือทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลสัญชาติใด
2. หลักสัญชาติ (Nationality Principle) ถือว่าสัญชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่ทำให้รัฐสามารถใช้เขตอำนาจของตนเหนือบุคคลซึ่งถือสัญชาติของรัฐ ตลอดจนทรัพย์สินที่มีสัญชาติของรัฐโดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ที่ใด
3. หลักป้องกัน (Protection Principle) รัฐสามารถใช้เขตอำนาจของตนเหนือบุคคลซึ่งกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจ เช่น การคบคิดกันล้มล้างรัฐบาล การจารกรรม การปลอมแปลงเงินตรา ตัวเงิน ดวงตรา แสตมป์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารมหาชนอื่น ๆ ซึ่งออกโดยรัฐ เป็นต้น แม้ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นบุคคลสัญชาติของรัฐ และการกระทำนั้นจะมีได้เกิดขึ้นภายในดินแดนของรัฐนั้นก็ตาม
4. หลักผู้ถูกกระทำ (Passive Personality Principle) หลักสัญชาติ และหลักผู้ถูกกระทำ (passive personality) ต่างก็อาศัยสัญชาติของบุคคลเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและรัฐ ผู้ใช้เขตอำนาจ แต่มีข้อแตกต่างกันคือ ตามหลักสัญชาติ รัฐสามารถใช้เขตอำนาจของตนโดยมีมูลฐานมาจากสัญชาติของผู้กระทำความผิด ในขณะที่ตามหลัก passive personality เขตอำนาจของรัฐกลับอาศัยมูลฐานจากสัญชาติของเหยื่อหรือผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำความผิด

5. หลักสากล (Universality Principle) รัฐใดๆก็ตามย่อมมีเขตอำนาจเหนืออาชญากรรมที่กระทบต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยส่วนรวม โดยไม่คำนึงว่าอาชญากรรมนั้นจะเกิดขึ้นในดินแดนของรัฐนั้นหรือไม่ และผู้กระทำหรือผู้ได้รับผลเสียหายจากการกระทำจะเป็นคนสัญชาติของรัฐใด ดังนั้น เขตอำนาจสากลจึงมีความเชื่อมโยงอยู่กับลักษณะของการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมเป็นสำคัญ ได้แก่ การจี้เครื่องบิน โจรสลัด การจับคนเป็นตัวประกัน การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย เป็นต้น

การพิจารณากรณีที่มีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องพิจารณาตามลำดับต่อไปนี้คือ ประเภทของบุคคล ประเภทของความผิด ฐานะพิเศษบางประการของผู้กระทำความผิด วิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผลการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และหลักทั่วไปของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

หลักทั่วไปของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจสรุปได้ดังนี้

1. บุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัว เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาหรือถูกลงโทษในทางอาญา ในเขตของประเทศผู้ร้องขอ หรือเป็นคดีอาญาที่มีมูลที่จะนำตัวผู้ต้องหาขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้
2. ต้องไม่ใช่คดีที่ขาดอายุความ หรือคดีที่ศาลของประเทศใดได้พิจารณาและพิพากษาให้ปล่อยหรือได้รับโทษในความผิดที่ร้องขอให้ส่งข้ามแดนแล้ว
3. บุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัว จะเป็นพลเมืองของประเทศผู้ร้องขอหรือของประเทศผู้รับคำขอ หรือของประเทศที่สามก็ได้
4. ความผิดซึ่งบุคคลผู้ถูกขอให้ส่งตัวได้กระทำให้ไปนั้น ต้องเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาของทั้งสองประเทศ คือประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้รับคำขอ (principle of double criminality)
5. ต้องเป็นความผิด ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (ตามอนุสัญญา Montevideo ค.ศ. 1933) และกฎหมายไทยก็ยึดถือหลักเกณฑ์นี้ด้วย
6. บุคคลผู้ถูกขอตัวได้ปรากฏตัวอยู่ในประเทศที่ถูกร้องขอให้ส่งตัว (ประเทศผู้รับคำขอ)
7. ประเทศเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ (ประเทศผู้ร้องขอ) เป็นผู้ดำเนินการร้องขอให้ส่งตัวโดยปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ครบถ้วนดังที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
8. ผู้ที่ถูกส่งตัวไปนั้น จะต้องถูกฟ้องเฉพาะในความผิดที่ระบุมาในคำขอให้ส่งตัวหรืออย่างน้อยที่สุด จะต้องเป็นความผิดที่มีระบุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างกัน
9. ต้องไม่ใช่ความผิดทางการเมือง เพราะมีหลักห้ามการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีการเมือง นอกจากนั้นยังมีความผิดบางประเภทซึ่งประเทศต่างๆ ไม่นิยมส่งผู้ร้ายข้ามแดน

หลักกฎหมายไทยกำหนดวิธีพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้สองวิธีคือ กรณีที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาหรือสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้กับประเทศผู้ร้องขอ ก็ให้พิจารณาสنธิสัญญาหรือสัญญานั้นเป็นหลักพิจารณา และกรณีที่ประเทศไม่มีสนธิสัญญาหรือสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้กับประเทศผู้ร้องขอก็ให้นำ

หลักทั่วๆ ไปในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 มาเป็นหลักพิจารณา และ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศผู้รับคำขอที่จะส่งหรือไม่ส่งก็ได้

วินิจฉัย

1. ประเทศใดบ้างมีเขตอำนาจรัฐในการดำเนินคดีจีเครื่องบินกับนายโมฮัมหมัดได้

ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าการกระทำของนายโมฮัมหมัดเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตอำนาจศาลตามมูลฐานหลักสากลที่ไม่คำนึงว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อความผิด และใครจะเป็นผู้เสียหายโดยตรง และ ไม่ว่าจะกระทำในเขตแดนของรัฐใดก็ตาม ทุกประเทศก็มีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนี้ ดังนั้น ประเทศที่มีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนี้ คือ ทุกประเทศ

2. ประเทศไทยมีเขตอำนาจรัฐที่จะดำเนินคดีต่อนายโมฮัมหมัดได้หรือไม่เพราะเหตุใดนั้น เมื่อทุกประเทศมีเขตอำนาจรัฐตามมูลฐานหลักสากล ดังนั้นประเทศไทยย่อมมีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนี้ด้วย แม้ว่าการกระทำในการจีเครื่องบินของนายโมฮัมหมัดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย และคนไทยไม่ได้เป็นผู้เสียหาย หรือ คนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเลยก็ตาม

3. หากประเทศออสเตรเลียจะร้องขอให้รัฐบาลไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังออสเตรเลียจะได้หรือไม่หากประเทศไทยและออสเตรเลียมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ในกรณีนี้ ประเทศออสเตรเลียก็มีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนี้ เช่นกัน ในกรณีของการมีเขตอำนาจรัฐทับซ้อน (Concurrent Jurisdiction) ซึ่งหมายถึงการที่มีประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศมีเขตอำนาจรัฐเหนือการกระทำอันเป็นความผิด ดังเช่นในกรณีนี้ประเทศที่จะใช้เขตอำนาจรัฐในการดำเนินคดี จะต้องเป็นประเทศที่ผู้กระทำผิดได้เข้าไปอยู่ในเขตอำนาจรัฐนั้นๆ ดังนั้นหากผู้กระทำผิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในเขตอำนาจรัฐนั้น ถึงแม้รัฐนั้นจะมีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีดังกล่าวก็จะไม่สามารถใช้อำนาจรัฐได้ เว้นแต่จะมีการขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อส่งตัวผู้กระทำผิดไปยังรัฐที่ร้องขอนั้น ดังนั้นประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีเขตอำนาจรัฐเหนือการกระทำผิดฐานจีเครื่องบิน จึงอยู่ในกรณีดังกล่าวนี้ หากประเทศออสเตรเลียประสงค์ที่จะขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศไทย ซึ่งผู้กระทำผิดได้เข้ามาอยู่ในเขตอำนาจรัฐของไทยแล้ว และประเทศไทยซึ่งมีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนี้ด้วยและมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศออสเตรเลียนั้น จะส่ง หรือ ไม่ส่งนายโมฮัมหมัดให้แก่ประเทศออสเตรเลียก็ได้ โดยปกติประเทศที่ได้ตัวผู้กระทำผิดหากไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงมักจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เช่นในกรณีของ ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในกรณีที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง มาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศที่ได้ตัวผู้กระทำผิดมักจะดำเนินคดีกับผู้นั้นเอง ในฐานะที่เป็นเจ้าของดินแดนที่ผู้กระทำผิดเข้ามาอยู่ในเขตอำนาจรัฐ เว้นแต่ประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าว เช่น อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น

สรุป

1. ทุกประเทศมีเขตอำนาจรัฐในการดำเนินคดีจี้เครื่องบินกับนายโมฮัมเหม็ดได้
2. ประเทศไทยมีเขตอำนาจรัฐที่จะดำเนินคดีต่อนายโมฮัมเหม็ดได้ตามมูลฐานหลักสากล
3. ประเทศออสเตรเลียจะร้องขอให้รัฐบาลไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังออสเตรเลียได้หากประเทศไทยและออสเตรเลียมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน แต่ประเทศไทยย่อมมีอำนาจอธิปไตยในการส่งหรือไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตอำนาจรัฐ และ มูลฐานในการกำหนดเขตอำนาจรัฐ การใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อสอบข้อนี้ได้แต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ส่วนนักศึกษาที่ตอบผิดมักจะไม่เข้าใจเขตอำนาจรัฐตามหลักสากล โดยตอบว่าการกระทำผิดไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยและ คนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดในคดีดังกล่าวเลย นอกจากนั้นนักศึกษาบางส่วนยังตอบผิดเกี่ยวกับการไม่มีเขตอำนาจรัฐของออสเตรเลีย ด้วยเหตุผลที่ว่า การกระทำผิด บุคคลที่กระทำผิด หรือผู้เสียหายไม่ได้เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียเลย เป็นต้น การตอบข้อสอบผิดในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ได้ศึกษามา เพราะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับเขตอำนาจรัฐ จึงแนะนำให้นักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือให้เข้าใจ วิชานี้ไม่ได้ยากหากได้ศึกษามาอย่างดี นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความรู้จึงจะสามารถสอบผ่านได้

คำถาม

นายเจฟฟรี เอกอัครราชทูต ชาวอังกฤษ ประจำประเทศ ฝรั่งเศส ได้นำรถยนต์ส่วนตัวของตนไปจอดอยู่ที่ ถนน ซองเอลิเซ ซึ่งเป็นที่ห้ามจอด จึงถูกตำรวจจราจรฝรั่งเศสจับ และถูกปรับ นายเจฟฟรีโต้แย้งว่าตนเป็นทูตได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต จะไม่ถูกจับ หรือ ปรับแต่ประการใด แต่ตำรวจฝรั่งเศสก็โต้แย้งว่า นายเจฟฟรี ไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่ทูต ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวและใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วย จึงไม่รับฟัง นายเจฟฟรีโกรธมาก จึงทำหนังสือประท้วงไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสและแจ้งรัฐบาลอังกฤษให้ทราบที่รัฐบาลฝรั่งเศสละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษจึงทำหนังสือประท้วงรัฐบาลฝรั่งเศสที่จับกุมเอกอัครราชทูตแล้วปรับ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทูต เนื่องจากทูตจะบริโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต นักศึกษาจงพิจารณาว่าในกรณีดังกล่าวนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องรับผิดชอบต่อทูตและรัฐบาลอังกฤษหรือไม่อย่างไร และ ข้อโต้แย้งของตำรวจจราจรฝรั่งเศสชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

“เอกสิทธิ์ทางทูต” เป็นสิทธิพิเศษของรัฐผู้รับที่ให้แก่ผู้แทนทางทูตของรัฐผู้ส่งตามทางปฏิบัติระหว่างประเทศอันเป็นประเพณีนิยม โดยอาศัยหลักอรรถาธิบายไมตรีและการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันเป็นมูลฐาน สิทธิพิเศษเช่นนี้อาจเป็นการให้ประโยชน์หรือให้ผลปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การให้สิทธิผู้แทนทางทูตมีโบสถ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การให้เกียรติในงานพิธี อาทิ การยิงสลุตให้ในเมื่อกองเรือรบของรัฐผู้ส่งเข้าไปในเมืองท่าของรัฐผู้รับ เป็นต้น หรืออาจเป็นการยกเว้นไม่ให้อำนาจปฏิบัติหรือไม่ให้ต้องรับภาระอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การยกเว้นไม่ต้องให้ผู้แทนทางทูตต้องปฏิบัติตามในฐานะของคนต่างด้าวในรัฐผู้รับ การยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้แทนทางทูต เป็นต้น

ส่วน “ความคุ้มกันทางทูต” นั้นเป็นสิทธิของรัฐผู้ส่งหรือที่รัฐผู้ส่งมีอยู่ในตัวตามกฎหมายระหว่างประเทศ และพึงสังเกตไว้ด้วยว่า ความคุ้มกันเป็นสิทธิของรัฐผู้ส่ง ไม่ใช่ของผู้แทนทางทูตของรัฐผู้ส่ง การสละความคุ้มกันจึงให้รัฐผู้ส่งเป็นผู้สละ ผู้แทนทางทูตจะสละเสียเองหาได้ไม่ ความคุ้มกันเช่นนี้ เป็นการยกเว้นให้ผู้ได้รับปลอดหรือหลุดพ้นจากอำนาจหรือภาระอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความคุ้มกันจากการจับกุม กักขังหรือจำขัง ความคุ้มกันจากอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล หรือจากการถูกฟ้องร้องคดียังโรงศาลของรัฐผู้รับ

เอกสิทธิ์ทางทูตได้แก่ เอกสิทธิ์ทางด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียม หรือค่าภาระที่เรียกเก็บในรัฐผู้รับ เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เอกสิทธิ์ทางด้านภาษีที่เกี่ยวกับสถานที่ของคณะผู้แทน กับเอกสิทธิ์ทางด้านภาษีของบุคคลในคณะผู้แทน

เอกสิทธิ์ทางด้านภาษีเกี่ยวกับสถานที่ของคณะผู้แทนนั้น โดยหลักแล้ว สถานที่ของคณะผู้แทนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐผู้ส่งหรือบุคคลที่ทำในนามของรัฐผู้ส่ง ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ ย่อมถูกยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ ดังต่อไปนี้คือ

(ก) ภาษีทางอ้อมชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้ว ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่บวกเข้าไปในราคาสินค้า เช่น ภาษีสินค้าของฟุ่มเฟือย เป็นต้น สำหรับภาษีทางอ้อมนี้ ตัวแทนทางการทูตมิได้รับการยกเว้นภาษี

(ข) ค่าที่ดิน และภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ ในนามของรัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทน

(ค) อากรกองมรดก การสืบทอดมรดก หรือการรับมรดกซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บ

(ง) ค่าที่ดิน และภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินหุ้นซึ่งได้ลงทุนประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับ

(จ) ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้

(จ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ค่าตีพิมพ์ในการจำนอง และอากรแสตมป์ ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ยังมีเอกสิทธิทางด้าน เสรีภาพในการคมนาคมสื่อสาร และ เอกสิทธิความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะไม่ถูกจับกุม คุมขังไม่ว่ารูปแบบใด ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใดต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต” เอกสิทธินี้ให้ความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเด็ดขาด และไม่จำกัดขอบเขต คือหมายความว่าครอบคลุมถึงการกระทำทุกประการ ไม่จำกัดเฉพาะแต่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น

สำหรับความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่ของคณะผู้แทน หรือความละเมิดมิได้เกี่ยวกับสถานที่ทำการของผู้แทนทางการทูต เป็นหลักกฎหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จากหลักดังกล่าวก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่รัฐผู้รับคือรัฐผู้รับจะต้องงดเว้นการกระทำที่เป็นสภาพบังคับ เช่น การบุกรุกเข้าไปในสถานทูตเพื่อกระทำการบางอย่าง และในขณะเดียวกันรัฐผู้รับก็ต้องให้ความคุ้มครองแก่สถานที่ดังกล่าวด้วย ความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่นี้ มิได้หมายความว่าถึงสถานที่ตั้งของคณะผู้แทนทางการทูตแต่อย่างใด แต่รวมถึงที่อยู่ส่วนตัวของผู้แทนทางการทูตด้วย ความคุ้มกันในสถานที่นี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้คณะผู้แทนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่บางส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่ทำการทางการทูต เพื่อปฏิบัติการควบคุม จับกุมบุคคลในสถานทูตเพื่อตรวจค้นเอกสาร เว้นเสียแต่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าคณะผู้แทน

วินิจฉัย

การที่นายเจฟฟรี เอกอัครราชทูต ชาวอังกฤษ ประจำประเทศ ฝรั่งเศส ได้นำรถยนต์ส่วนตัวของตนไปจอดอยู่ที่ ถนน ซองเอลิเซ ซึ่งเป็นที่ห้ามจอด และได้ถูกตำรวจจราจรฝรั่งเศสจับ และถูกปรับ นายเจฟฟรีโต้แย้งว่าตนเป็นทูตได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต จะไม่ถูกจับ หรือ ปรับแต่ประการใด แต่ตำรวจฝรั่งเศสก็ได้แย้งว่า นายเจฟฟรี ไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่ทูต ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวและใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วย จึงไม่รับฟังนั้นไม่ชอบเพราะกฎหมายการทูตกำหนดให้เอกสิทธิความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะไม่ถูกจับกุม คุมขังไม่ว่ารูปแบบใด และให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใดต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต เอกสิทธินี้ให้ความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเด็ดขาด และไม่จำกัดขอบเขต คือหมายความว่าครอบคลุมถึงการกระทำทุกประการ ไม่จำกัดเฉพาะแต่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น

สรุป

รัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องรับผิดชอบต่อทูตและรัฐบาลอังกฤษ และ ข้อโต้แย้งของตำรวจจราจรฝรั่งเศสไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเอกสิทธิและความคุ้มกันในตัวบุคคลอันละเมิดมิได้นั้นเป็นเอกสิทธิเด็ดขาดไม่จำกัด

เฉพาะแต่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น อย่างไรก็ตามตัวทูตเองจะต้องมีสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเคารพต่อกฎหมายของรัฐผู้รับด้วย

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินความรู้ของนักศึกษา เกี่ยวกับ เอกสิทธิ และความคุ้มกันทางการทูตว่านักศึกษามีความรู้ และสามารถวิเคราะห์ การปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตอบข้อสอบนี้ได้ แต่มีนักศึกษาบางส่วนที่ตอบผิดโดย ตอบว่า การกระทำของทูตที่ผิดกฎหมายในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกัน ซึ่งหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มกันนี้ในข้อนี้ต้องการที่จะให้ความคุ้มกันทูตแบบเด็ดขาดเพื่อให้ทูตปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่